

0006205-55.2020.8.26.0451

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... em juízo (gravação), novamente negou o tráfico, mas deu versão parcialmente diferente para os fatos. Disse que, no dia da ocorrência, acordou, foi à padaria onde comprou cigarro, isqueiro e refrigerante. Na volta, encontrou Luana, uma moça que realiza tráfico no local dos fatos, a qual lhe pediu cigarro. Neste momento, ambos foram abordados pela polícia. Os agentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1 0006205-55.2020.8.26.0451 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006205-55.2020.8.26.0451

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2104/2020 -

Seccional - Piracicaba, 2168556/2020 - 07º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Allan David Nascimento Tanguí

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos,

ALLAN DAVID NASCIMENTO TANGUI, vulgo "PC", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia e seu aditamento (fls. 216), no dia 10 de julho de 2020, por volta das 11,50 horas, na rua Armando Bogus, defronte à creche municipal "Raquel de Queiroz", bairro Pompeia, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 75 eppendorfs contendo cocaína em pó, com peso bruto aproximado de 169,4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11/2, laudo de constatação de fls. 15/17 e fotografia de fls. 18).

Narra a denúncia que policiais militares do BAEP patrulhavam pelo local quando

avistaram o acusado nas imediações da creche, em atitude suspeita, entregando um objeto a uma moça (Luana).

Notando a aproximação dos PMs, Allan jogou o tal objeto ao solo. O réu e a moça foram abordados, verificando-se que o acusado tinha em seu poder 4 eppendorfs contendo cocaína e R\$ 39,70 em dinheiro trocado.

Nas entrevistas feitas com Allan e Luana foi esclarecido que, no momento da abordagem, o acusado vendia um pino de cocaína para a mulher por R\$ 10,00. Também se descobriu que o acusado se dedicava ao tráfico e que, a cada 20 eppendorfs que vendia, lucrava 5 porções.

Narra, ainda, a denúncia que Allan mostrou aos PMs onde guardava e tinha em depósito o restante das drogas, conduzindo-os a uma árvore, distante 5 metros do local da abordagem, onde havia uma capa de óculos e, dentro dela, as demais porções de cocaína mencionadas no primeiro parágrafo.

Conclui a denúncia que as circunstâncias da prisão, a confissão informal do réu e a quantidade de droga revelaram que as porções apreendidas se destinavam ao tráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 147). Defesa preliminar apresentada às fls. 151/158. Após, a denúncia foi recebida (fls. 175/176) e o réu foi citado (fls. 198).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Na fase de requerimentos de diligências (fls. 216), o Ministério Público aditou a denúncia, sem alterar a classificação jurídica, para dela constar que, além da creche, o local dos fatos possui equipamentos públicos, como campo, quadra de esportes e parquinho infantil e unidade de saúde, e que, na ocasião, havia pessoas praticando esportes e realizando atividades lúdicas.

Após oitiva da defesa, o aditamento foi recebido (fls. 216) e passou-se à inquirição de mais uma testemunha arrolada pelo réu, o qual foi novamente interrogado.

A defesa requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica (fls. 217), o que foi deferido (fls. 222/223).

Instaurado incidente de dependência toxicológica (fls. 222/223), o laudo foi juntado às fls. 71/75 dos autos de n. 0009349-37.2020 (em apenso), concluindo que o réu "não apresenta atualmente quadro de doença mental ou perturbação da saúde mental" e "não havia prejuízo da capacidade de entendimento e de determinação à época dos fatos", de modo que era capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, bem como determinar-se de acordo com tal entendimento, tratando-se, portanto, de pessoa imputável.

Por decisão de fls. 88 (autos em apenso) o laudo foi homologado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, com aplicação da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito, bem assim a majorante. Pleiteou o reconhecimento da agravante da reincidência e a fixação de regime fechado para o início de cumprimento de pena (fls. 270/273).

A Defesa pediu a absolvição, por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06. No caso de

condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento da majorante do artigo 40, inciso III, da referida Lei. Por fim, pleiteou o reconhecimento do privilégio e fixação do regime inicial diverso do fechado para o início de cumprimento de pena (fls. 276/282).

É o relatório.

Decido.

A denúncia e seu aditamento procedem.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos: boletim de ocorrência de fls. 08/10; auto de exibição e apreensão de fls. 11/12; fotografia de fls. 18; laudo de constatação preliminar de fls. 15/17 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 177/179, ambos com resultados positivos para cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 06), o réu negou o crime. Disse que é usuário de entorpecentes e que na data dos fatos tinha ido comprar cigarros, sendo abordado quando falava com uma moça que lhe pediu um cigarro. Afirmou que nenhuma droga foi encontrada em seu poder, havendo apenas um pino de cocaína nas proximidades, mas não soube dizer a quem pertencia. Alegou que, antes de ser encaminhado à delegacia, os policiais foram até um lugar desconhecido e, dentro da viatura, começaram a contar alguns “pinos” que ali recolheram. Por fim, afirmou que os policiais pegaram um pouco de dinheiro de cada um e apresentaram à Autoridade Policial como se fosse como se pertencesse tudo a ele (o interrogando).

Interrogado em juízo (gravação), novamente negou o tráfico, mas deu versão parcialmente diferente para os fatos. Disse que, no dia da ocorrência, acordou, foi à padaria onde comprou cigarro, isqueiro e refrigerante. Na volta, encontrou Luana, uma moça que realiza tráfico no local dos fatos, a qual lhe pediu cigarro. Neste momento, ambos foram abordados pela polícia. Os agentes encontraram drogas com Luana (não soube dizer quanto nem que tipo de droga, mas achou que era cocaína). Viu também que os policiais encontraram entorpecentes da cor amarela no pé da árvore. Disse que eles lhe perguntaram se conhecia o traficante que atuava no local, mas não contou que era Luana, pois não queria prejudicá-la. Após, ambos foram levados à delegacia da Avenida Armando Sales. Lá os policiais Moreira e Tania entraram. Depois eles pegaram uma pochete azul que estava na viatura, com cápsulas azuis, fizeram uma “vaquinha” para arrecadar dinheiro e disseram que iriam acusá-lo de tráfico. Afirmou que só soube da quantidade de droga que eles apresentaram à autoridade policial quando recebeu a citação do oficial de justiça. Alegou que foi agredido pelos policiais, pessoas que não conhecia anteriormente, e que só foi acusado injustamente porque não indicou quem era o traficante daquela área. Admitiu que, no local dos fatos, além de haver uma escola, há também uma área de lazer, com parquinho e campo de futebol, mas afirmou que estavam vazios no horário dos fatos. Por fim, declarou que, em 2019 ficou alguns dias internado em clínica de desintoxicação, depois foi trabalhar com carteira registrada no SESI, onde ficou até março deste ano, sendo dispensado somente por causa da epidemia, passando, então, a trabalhar com bicos de pintor.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 02) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial militar Rodrigo Lopes Moreira declarou que estava com sua equipe patrulhando pelo bairro Alvorada. Quando trafegavam pela rua Armando Bogus,

visualizaram, ao lado da creche municipal "Rachel de Queiroz" e uma área de lazer (parquinho infantil, quadra e campo), o acusado entregando algo para uma moça. Ao notar a aproximação da viatura, ele jogou o objeto ao solo e tentou empreender fuga, mas foi abordado. A moça também foi abordada e, com ela, nada de ilícito foi encontrado. Com o réu, encontraram 4 pinos contendo cocaína e a quantia de R\$ 39,70 em notas trocadas. A moça foi identificada como Luana e informou que havia entregado R\$ 10,00 para o réu para comprar dele um pino de cocaína. Ele, por sua vez, disse que é dependente químico e que vendia drogas para sustentar o vício, recebendo 5 porções a cada 20 vendidas. Por fim, disse que questionaram o réu sobre onde estava o restante das drogas que vendia e ele lhes indicou o local. Assim, atrás de uma árvore, a 5 metros dele, encontraram um pochete do tipo de capa de óculos contendo mais pinos de cocaína, idênticos aos encontrados no bolso da sua calça. Esclareceu que, no local dos fatos, além de haver uma escola, há também uma área de lazer, com parquinho e campo de futebol, havendo diversas pessoas no momento.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 04) e em juízo (gravação) pela policial militar Tania Tiemi de Abreu Matumoto, a qual apenas divergiu de seu colega ao afirmar que, quando ela olhou para o local dos fatos, o réu estava agachado junto à árvore onde posteriormente encontraram drogas e, ao se levantar e entregar a porção de cocaína à moça, viu a viatura, jogou a droga ao solo e tentou fugir.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

A alegação do réu de que foi agredido por eles no dia dos fatos não encontra amparo em qualquer elemento dos autos. Contrariamente, foi afastada pelo laudo pericial de exame de corpo de delito ao qual ele se submeteu no dia dos fatos (fls. 98), indicando que não apresentava lesões corporais.

Por outro lado, não há divergências importantes em seus depoimentos, notadamente sobre o fato principal, que foi o encontro do dinheiro e das drogas, bem assim, da entrega que o réu fazia a Luana quando se aproximaram.

A aparente contradição entre os relatos dos agentes não infirma seus depoimentos, porquanto perfeitamente explicável, como bem se viu no depoimento do PM Rodrigo.

De fato, indagado sobre o fato de a PM Tania ter visto o réu agachado junto à árvore antes de ele se levantar e entregar algo a Luana, fato não presenciado pelo PM Rodrigo, este disse que, durante o patrulhamento, muitas vezes, os policiais olham em direções diferentes, o que justificaria o fato de, quando ele olhou para a cena do crime, o réu já estar entregando o objeto à moça.

No mais, presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confirmam-se alguns julgados neste sentido:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA

FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos policiais militares: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daqueles é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Os relatos dos agentes policiais não foram infirmados pelas demais provas dos

autos.

Graziela dos Santos Silva, ouvida em juízo (gravação), declarou apenas que o réu casado com sua cunhada e o conhece há 4 anos. Não viu a abordagem. Sabe que ele é usuário de drogas, vendia os objetos da casa para comprar entorpecente e procurava ajuda para se livrar do vício. Disse não conhecer o local dos fatos nem Luana. Nunca soube que o acusado tenha se envolvido com a venda de drogas.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo e tinha em depósito 75 eppendorfs contendo cocaína, para fins de mercancia.

De fato, a versão totalmente inverossímil do acusado (os policiais, além de forjarem o encontro de drogas com ele pelo simples fato de não lhes dizer quem era o traficante que atuava naquele local, fizeram uma "vaquinha" para arrecadar a quantia apresentada na delegacia somente para incriminá-lo), foi completamente afastada nos autos.

Os policiais, sobre os quais, repita-se, não recai qualquer suspeita, foram uníssonos e convergentes no sentido de que visualizaram o acusado entregando algo para uma moça, em atitude típica de tráfico e, ao notar a aproximação da viatura, ele jogou o objeto ao solo e tentou empreender fuga.

Também foram seguros ao declarar que, com o réu foi encontrado dinheiro trocado e 04 pinos de cocaína, bem assim que, ao pé da árvore próxima de onde ele estava, foram encontradas mais 70 porções de cocaína, embaladas de forma idêntica às encontrados com ele, em eppendorfs de diversas cores.

Por serem idênticas as porções e devido ao fato de o réu ter sido visto pela policial Tania mexendo no exato local onde estavam escondidas as drogas, não há dúvidas de que todos os entorpecentes pertenciam a ele e eram destinados à venda.

Some-se a isso a atitude do réu, típica do tráfico, de ter sido visto entregando um objeto à moça, a qual, no calor da diligência, confirmou estar adquirindo droga dele.

Confirma o destino mercantil dos entorpecentes o fato de estarem embalados em porções individuais e ser expressiva a quantidade apreendida, o que é incompatível a situação de mero usuário.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não esbanja a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Destarte, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

É caso, ainda, de se reconhecer a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

A prova acima analisada demonstrou que o local em que o réu exercia o tráfico de droga, além de ser próximo de uma creche, também consistia em área de lazer contendo equipamentos públicos, como campo, quadra de esportes, parquinho infantil e unidade de saúde, tratando-se, portanto, de local frequentado por diversas pessoas, inclusive crianças, o que enseja o aumento da reprimenda nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porquanto trata-se de caso de traficante que distribui, vende, fornece entorpecentes nas proximidades de locais em que há mais facilidade de difusão do vício pela maior concentração de pessoas.

Fixada, dessa forma, a responsabilidade penal do acusado, passo à individualização das penas, ressaltando-se que, de acordo com a conclusão do incidente de dependência toxicológica instaurado, submetido ao crivo das partes e devidamente homologado (fls. 88 - autos em apenso), o réu é imputável (fls. 71/75 - autos em apenso).

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência (fls. 42/43), o que enseja o aumento da reprimenda em 1/6, perfazendo cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Não se fazem presentes circunstâncias atenuantes nem causas de diminuição de penas.

Reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, em razão de a infração ter sido cometida próximo à creche e em área de lazer (frequentada por diversas pessoas, inclusive crianças, havendo pessoas no momento dos fatos), imperioso o aumento das penas em 1/6, o que perfaz seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa.

Registro que, por expressa disposição legal, a reincidência impede a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.334/06 e impõe a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis (esses também incabíveis em razão da quantidade de pena aplicada), pois indica que o réu vem reiterando na prática de crimes.

Acrescente-se a isso as graves consequências do delito de tráfico, que fomenta a prática de vários outros crimes, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, no crime de tráfico de drogas se a natureza, a reincidência e as circunstâncias concretas do crime indicarem tratar-se de agente de maior periculosidade.

Confira-se julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito - Apreensão de 988,5 gramas de maconha - Recurso defensivo - Pleito de absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Autoria, materialidade e culpabilidade, comprovadas pelas declarações dos policiais militares - Relevância de suas palavras porque prestam compromisso e estão sujeitos às penas por falso testemunho - Prática de condutas previstas no tipo penal do art. 33, da Lei de Drogas (guardar e ter em depósito) - Desclassificação da imputação para a rubrica do art. 28, da mesma lei - Destinação mercantil, demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto - Crime de tráfico caracterizado - Condenação, mantida - Dosimetria - Sanções majoradas em razão da comprovada reincidência e da presença da causa especial de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade de substituição da carcerária por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis, diante do quantum e da recidiva (CP, arts. 44, caput, I e II, e 77, caput e I) - Regime (fechado) pertinente, em razão da natureza do delito e da reincidência - Erro material relativo ao quantum da multa, retificado - Apelo não provido." (TJSP - Apelação 0024121-80.2015.8.26.0224. 5ª Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Juvenal Duarte - j. 31/08/2017).

Registro, ainda, que o reconhecimento da reincidência para fins de impedir a concessão de benefícios ao acusado e apená-lo de forma mais grave não fere a coisa julgada, nem constitui "bis in idem", pois não se trata de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, essa ideia "peca pela simplicidade. O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)" (CPComentado - RT, 13ª ed., pag. 464).

Ao se reconhecer a reincidência e aumentar a pena do crime em razão dessa agravante ou deixar de aplicar ao réu alguma benesse, o Estado nada mais faz do que punir com maior rigor o agente que, tonando a delinquir, desafia a ordem pública e as leis vigentes, demonstrando, no dizer do professor Nucci, "persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte, sofre uma punição mais severa" (obra citada, pag. 464).

Pelos mesmos motivos, fica vedado o direito do réu apelar em liberdade, pois necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Anoto, por fim, que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o tempo de prisão cautelar do réu não é suficiente para cumprir o requisito objetivo para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu ALLAN DAVID NASCIMENTO TANGUI a cumprir seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar seiscentos e oitenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida em poder do acusado, cuja origem lícita não foi comprovada, é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Conforme acima exposto, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, o que indica real possibilidade de reiteração criminosa, fato que, aliado à grande quantidade de droga apreendida, revela maior periculosidade, graves consequências e seu desprezo pela sociedade, sendo, portanto, necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra preso, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

P.R.I.C.

Piracicaba, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA